

조정 관행의 개념적 구조와 요소*

—관행 개념 재구성과 대안 이론을 위한 분석적 기초—

이현경**

〈국문초록〉

관행은 일반시민들의 법생활뿐 아니라 법이론과 법실무에 있어서도 매우 중요한 역할을 한다. 그러나 관행의 개념과 본성, 그리고 효력과 법적 위상 등에 대한 본격적인 법철학적 연구는 충분하지 못한 실정이다.

사회적 관행에 대한 기존의 연구는 크게 세 흐름으로 정리될 수 있다. ① 관행을 조정 문제에 대한 해결책으로 정의하는 입장(홉-루이스의 ‘조정 해법 모델’), ② 루이스의 기본 전제를 거부하며 등장한 대안적 접근들(‘대항 모델’)이 있다. 그리고 ③ 루이스적 조정 관행을 수용하면서도 그 이론이 설명하지 못하는 새로운 관행 유형을 제시한 마머의 보완적인 관행 이론(‘복합 모델’)이

DOI: 10.22286/kjlp.2017.20.1.005

* 본고는 필자의 법학박사학위논문 “관행에 관한 연구: 사회적 관행에서 법적 관행으로”(서울대학교, 2016.8) 제3장을 중심으로 내용 일부를 발췌하고 수정·보완한 것임.

** 서울대 법이론연구센터 전임연구원, 대구경북과학기술원 대우교수, 법학박사.

*** 투고일자 2017년 3월 10일, 심사일자 2017년 4월 7일, 게재확정일자 2017년 4월 11일.

있다. 본고에서는 그 중 가장 표준적인 설명으로 이해되는 ‘조정 해법 모델’을 중심으로 조정 관행의 개념적 구조와 요소를 분석한다.

조정 관행 모델은 ① ‘상황 요소’로서 조정 문제와 ② 그에 대한 규범적 응답의 일종인 ‘해법 요소’, 그리고 ③ ‘상호작용 요소’로 구성된다. 이 중 본고에서는 ‘상황 요소’와 ‘해법 요소’를 중심으로 관행의 개념적 구조를 분석한다. 이러한 분석을 통해 필자는 기존의 조정 관행 모델은 여러 장점들에도 불구하고 두 차원—사회적 관행에 관한 ‘일반 이론’의 차원과 ‘법이론’의 차원—에서 문제점과 한계를 갖는다고 지적한다. 전자는 관행에 대한 경직된 관념과 정적인 접근에 머물러있어 관행의 ‘역동성과 복잡성’을 적절히 포착하지 못하는 점, 후자는 특히 관행의 ‘규범성’을 충분히 해명하지 못함을 의미한다. 기존의 조정 관행 이론들이 갖는 이러한 결함을 극복하기 위해 필자는 궁극적으로 ‘대안적인 법학적 관행 이론’ 정립이 필요하다고 주장한다. 대안 이론은 ‘법적 관행’ 개념 재구성을 포함하며, 나아가 ‘관행의 역동성’(관행 동학), ‘관행의 복잡성’(관행 생태학), 그리고 ‘관행의 규범성’(관행 규범학) 해명이라는 세 가지 점을 구성적 요소로 갖는다. 관행의 개념적 구조와 요소를 분석한 본고의 탐구는 이러한 대안적인 법학적 관행 이론 구축을 위한 분석적 기초를 마련하는데 기여할 수 있을 것이다.

I. 들어가며

1. 법에 있어서의 관행

법에 있어 관행의 문제는 대단히 중요하다. 관행 개념은 대표적으로 두 가지 차원에서 중요한 의미를 갖는데, 하나는 법원(法源)론의 일종으로서 관행 그 자체에 관한 문제이고, 다른 하나는 법의 본성과 토대, 기원을 해명하고 법적 권위를 정당화하는 중요한 도구적 개념으로서 관행의 차원이다. 전자가 사회적 관행 이론과 보다 가깝다면, 후자는 법관행주의(legal conventionalism)의 핵심을 이룬다. 법적 영역에서 관행은 추상적인 이론의 차원을 넘어 구체적인 판결에서도 큰 의의를 갖는다. 예전에는 관행이 주로 ‘관습법’의 객관적

구성요건으로 다루어졌지만, 최근에는 ‘관행 그 자체’를 법적 판단의 대상으로 삼거나¹⁾ 법률해석의 기준 혹은 판결의 정당화 근거로 고려하는 경우들이 늘어나고 있다. 즉, 관행의 개념과 효력이 사법 판결에서도 매우 중요하게 다루어지고 있다. 이렇듯 법이론적·법실무적으로 관행은 대단히 중요한 역할을 하고 있지만, ‘관행 그 자체’에 대한 본격적인 법철학적 연구는 충분하지 못한 실정이다.²⁾ 즉, 관행의 개념과 본성, 그리고 관행의 규범성과 효력 및 법적 위상 등에 대한 근본적인 이론적 연구가 필요하다. 하지만 법학의 영역에서는 이에 관한 적합한 연구를 찾기가 쉽지 않다. 따라서 인접 학문 영역, 예컨대 철학이나 사회학 등에서 논의되어 온 사회적 관행 이론들을 참고함으로써 법학적 관행 이론 정립의 유용한 이론적 자원을 구할 수 있을 것이다.

2. 사회적 관행 이론의 전개

기존의 사회적 관행 이론들의 발전 양상은 크게 세 흐름으로 정리할 수 있

1) ‘관행 그 자체’를 다룬 최근 판례들로는 대표적으로, (가) 대법원 2011.5.13. 선고 2008두18250판결(‘비과세관행의 성립과 소멸’), (나) 대법원 2013.12.26. 선고 2011두 5960판결(‘비과세 관행 존중의 원칙’), (다) 대법원 2014.2.27. 선고 2011다109531판결(근로계약과 노동관행-‘전기요금 지원관행’), (라) 대법원 2013.2.15. 선고 2011도 5835판결(‘저작물 인용’), (마) 대법원 2013.12.18. 선고 2012다89399, 2012다94643 전원합의체 판결(통상임금) 등이 있다.

2) 국내 법철학 분야에 한정하면, 관행이나 관행주의를 다룬 대표적 저술은 다음과 같다. 박준석, “관행과 법의 지배,” 법철학연구, 제16권 제3호(한국법철학회, 2013); 안준홍, “87년 체제와 승인규칙의 변화,” 외법논집, 제36권 제4호(2012); 안준홍, “승인율의 규범성에 대한 일 고찰,” 법철학연구, 제16권 제3호(한국법철학회, 2013); 양선숙, “수도-서울 명제의 ‘관습헌법’ 성립에 대한 비판적 검토,” 법철학연구, 제9권 제2호(한국법철학회, 2006); 양선숙, “흙의 정의론 연구-재산권 규칙의 정립과 관련한 묵계(Convention)를 중심으로,” 부산대학교 법학연구, 제51권 제4호 (2010); 양선숙, “법, 규범성, 그리고 규칙 준수의 동기에 대한 관행론적 이해,” 법철학연구, 제15권 제3권(한국법철학회, 2012); 이정훈, “법실증주의 승인율과 관행에 관한 연구,” 법철학연구, 제10권 제2호(한국법철학회, 2007); 이정훈, “포용적 법실증주의 법개념 연구: 조선시대 법개념 분석을 중심으로,” 서울대학교 대학원 법학박사학위논문(2008); 이정훈, “법개념 논쟁을 통해 본 관행과 법해석의 재량,” 문학·사학·철학, 제15호(2008).

다.³⁾ 우선 사회적 관행 이론의 고전적인 흄(David Hume)⁴⁾과 루이스(David Lewis)⁵⁾를 대표로 한 ‘조정 해법 모델’과 그것을 정교화하여 발전적으로 계승해온 흐름이 있다(‘조정 해법 모델’). 이는 주로 게임 이론에 더 얽은 경제학 분야를 중심으로 발전되어 왔다. 반면에 루이스적 관행 이론의 기본 전제들을 거부하면서 전면적 대안을 주장하는 이론들이 있다. 대표적으로 길버트(Margaret Gilbert), 밀러(Seumas Miller),⁶⁾ 밀리칸(Ruth Millikan)⁷⁾ 등의 연구를 꼽을 수 있다(‘대항 모델’). 그리고 루이스적 조정 관행 모델을 받아들이면서도, 구성적 관행, 심층·표층 관행이라는 새로운 유형을 추가하여 조정 관행 모델을 보완한 마머의 사회적 관행 이론이 있다(‘복합 모델’). 특히 마머는 법체계를 이루는 모든 법들의 효력 근거가 되는 토대 규범의 본성을 관행으로 설명한다는 점에서 또 하나의 특별함을 갖는다.

3. 조정 해법으로서의 관행

이러한 사회적 관행 이론들의 발전 흐름과 전체 지형 안에서 ‘조정 관행 모델’이 관행에 대한 표준적인 설명으로 이해된다. ‘조정 관행(coordination convention)’은 ‘거듭 반복하여 발생하는 조정 문제를 해결하기 위해 마련된 해법’으로 간략히 정의할 수 있다. 이런 설명은 특히 루이스 이래로 발전해 온 게임 이론적 관행 이론을 중심으로 잘 표현된다. 다른 계열의 대표적인 관행

3) 이에 관한 상세한 설명은 이현경, “사회적 관행 이론의 세 모델: 비판적 고찰”, 법학논집 제21권 제3호, 2017. 참고.

4) David Hume, *A Treatise of Human Nature*, L.A.Selly-Bigge(Ed.)(Oxford Clarendon Press, 1955).

5) David Lewis, *Convention* (Blackwell Publishing, 1969).

6) Seumas Miller, “Truth-telling and the Actual Language Relation,” *Philosophical Studies*(1986); Seumas Miller, “Conventions, Interdependence of Action, and Collective Ends,” *Nous*(1986); Seumas Miller, “Rationalizing Conventions,” *Synthese*(1990); Miller, Seumas Miller, *Social Action: A Teleological Account* (Cambridge University Press, 2001).

7) Ruth Millikan, *Language: A Biological Model*(Oxford University Press, 2005); Ruth Millikan, “A Difference of Some Consequence Between Conventions and Rule,” *Topoi*(2008).

이론들도 대부분 게임 이론에 기초한 루이스적 조정 관행 모델에 대한 비판이나 발전적 계승을 연구의 발판으로 삼고 있다. 따라서 이 모델에 대한 일부 한계들이 지적됨에도 불구하고, 대안 이론 정립을 위한 심층적 분석 및 개선을 위한 출발점으로는 조정 해법 모델이 적합할 것 같다. 이러한 배경 하에, 본고에서는 루이스적 관행 모델⁸⁾을 기초로 조정 관행의 개념적 구조를 밝히고 구성 요소들을 면밀히 검토한다.

조정 관행은 다음의 세 요소를 중심으로 구성된다. ① ‘상황 요소’로서 조정 문제와 ② 그에 대한 규범적 응답의 일종인 ‘해법 요소’, 그리고 ③ ‘상호작용 요소’가 조정 관행의 기본 구조를 이룬다. 또한 어떠한 관행관(conception)을 취하는지에 따라 관행이 담고 있는 목적이나 가치, 원리 요소 등도 중요하게 고려될 수 있다. 이 세 가지 요소 중 특히 ‘상황 요소’와 ‘해법 요소’가 관행 개념의 구조적인 골격을 이루며 특정한 관행관과도 밀접한 관련을 맺는다. 따라서 본고에서는 이 두 요소를 중심으로 조정 관행의 개념적 구조와 요소를 분석한다. 그리고 기존의 조정 해법 관행 모델의 문제점과 한계들을 지적

- 8) 본고에서는 루이스의 관행 이론 자체를 상세하게 다루지는 않는다. 왜냐하면 이 글의 목표는 루이스의 이론이 아닌 조정 관행 모델 자체를 분석 대상으로 삼기 때문이다. 루이스의 관행 이론과 그에 대한 비판적 검토는, 이현경, 앞의 글(주3), 제2장 제1절 참고. 루이스의 관행 정식은 다음과 같다.

■ 일정 규모의 인구집단 P(Population)의 구성원들이 반복적으로 야기되는 상황 S에 위치한 행위자일 때 그들의 행동으로부터 규칙적으로 일어나는 현상 R(Regularity, 이하 ‘정규성’)은 만일 P의 성원들 가운데 S의 어떠한 상황 하에서도 다음과 같은 사실이 참이고 또한 P의 사회에서 공통 지식(common knowledge)인 오직 그 경우에 만 관행이 된다.

- (1) 거의 모든 사람들이 R을 준수한다.
- (2) 거의 모든 사람들이 자기 이외의 거의 모든 사람들이 R을 준수하기를 기대한다.
- (3) 거의 모든 사람들이 행위의 모든 가능한 조합들에 대해 대략 같은 선호를 갖는다.
- (4) 거의 모든 사람들은, 거의 모든 사람들이 R을 준수한다는 조건 하에서 누구라도 R을 준수하기를 선호한다.
- (5) 거의 모든 사람들이 R*를 준수한다는 조건 하에서라면, 거의 모든 사람들은 누구라도 R*를 더 많이 준수하기를 선호할 것이다.

S에서 P의 구성원의 행위 안에서 R*가 가능한 정규성이면, P의 구성원들 사이에서 S의 그 어떤 상황에서도 어느 누구도 R*와 R을 동시에 준수할 수 없다.

하면서, 궁극적으로는 관행 개념의 재구성과 대안 이론 마련의 필요성을 제기한다. 이를 위해 필요한 한에서 각 요소들을 적절히 수정·개선하는 시도를 한다. 나아가 대안 이론이 갖춰야 할 필수적인 구성적 요소들을 제안한다.

II. 상황 요소

1. 게임 이론적 조정 문제 모델과 그 한계

조정 문제는 상호 의존적인 결정의 상황에 처함으로써 구별되는 상호작용 상황들이다. 둘 이상의 사람들이 관련되며 그 안에서 각자는 수 개의 대안적 행위들 중에서 하나를 선택해야 하고, 각자의 행위 결과는 다른 이들이 선택한 행위들에 의존한다. 따라서 각인에게 있어 최선의 선택은 다른 사람들이 행할 것이라고 그가 기대하는 것에 의존하는데, 이는 다른 사람들도 그가 할 것 같은 것을 추측하고자 애쓴다는 전제 하에 그러하다.⁹⁾ 울만-마가릿(Edna Ullmann-Margalit)은 조정 상황을 다음과 같이 설명한다.

조정의 상황들(문제들, 게임들)은 이 용어에 관한 엄격하게 기술적(technical)인 의미에서, 일종의 **전략의 상황들(문제들, 게임들)**의 유개념이다.¹⁰⁾

인용문에서도 확인할 수 있듯이, 전통적인 조정 관행 모델은 게임 이론¹¹⁾의 틀을 전제로 한다. 그리고 ‘조정 상황 = 조정 문제 = 조정 게임’을 등치시키며, 관행 형성의 배경적 여건의 범위를 게임 이론적 조정 문제로 제한하기

9) Edna Ullmann-Margalit, *The Emergence of Norms* (Oxford University Press, 1977), 78면.

10) Ullmann-Margalit, 위의 책(주9), 78면(강조는 필자에 의한 것).

11) 게임 이론이란 행위자들 간의 전략적 상호작용을 분석하는 이론이다. 게임 이론은 경기자(player), 전략(strategy), 보수(payoff)를 필수 요소로 이루어진다. 게임 이론과 법의 관계를 다룬 대표적인 단행본으로는, Douglas G. Robert H. Baird · Gertner · Randa C. Picker, *Game Theory and the Law* (Harvard University Press, 1998).

도 한다. 그런데 게임이란 반드시 승패가 전제된 경쟁적 놀이이자 경기자가 달성해야 할 각자의 목표와 타산적 이익이 분명하다는 점에서 ‘상황’ 혹은 ‘문제’라는 표현이 담고 있는 것 이상의 특별한 의미가 더해진다. 게임 이론적 조정 문제관의 이런 특징이 사회적 관행 일반에 대한 설명력에 있어서는 장애 요소로 작용할 수도 있다.

(1) 게임 이론적 조정 문제

게임 이론이 만든 두 패러다임 게임으로는 ‘죄수의 딜레마’¹²⁾와 ‘조정 문제’가 있다. 그리고 조정 문제 안에서도 ‘순수 조정 문제’와 ‘비-순수 조정 문제’가 있다. ‘순수 조정 문제’는 당사자들의 이해관심의 우연적 일치가 완벽한 상황을 말한다. ‘비-순수 조정 문제’는 이해관심의 수렴은 불완전하지만 이익들의 가능한 충돌을 여전히 압도한다는 특징이 있다. 정치철학이나 법철학 분야에서 논의되는 상황은 후자, 즉 비-순수 조정 문제나 ‘부분 갈등 게임’의 상황에 해당한다.

게임 이론을 기반으로 한 ‘루이스 식의 조정 문제’¹³⁾에서 그가 최초로 염두

12) ■ 죄수의 딜레마

		용의자 II	
		협 의사실 부인	자백
용의자 I	협 의사실 부인	-1, -1	-7, 0
	자백	0, -7	-5, -5

■ 죄수의 딜레마상황의 일반화

		경기자 II	
		협조	배신
경기자 I	협조	B, B	D, A
	배신	A, D	C, C

게임의 보수가 각각 A, B, C, D로 표현될 때, 만일 ① $A > B > C > D$ 가 성립하고, (배신이 협조보다 우월 전략이 되고), ② $C > (A+D)/2$ 가 성립하면(모든 경기자가 ‘협조’전략을 선택하는 것이 사회적으로 최적이 되어야 한다). 이 게임은 죄수의 딜레마 게임이 된다.

- 13) “루이스 식의 조정 관행(Lewis-type coordination conventions)”이란 표현은 마머의 책에서도 발견된다. Andrei Marmor, *Social Conventions: From Language to Law* (Princeton University Press), 36면. 게임 이론적 조정 문제는 루이스 식의 조정 문제를 포함하지만, 훨씬 더 많은 종류의 조정 문제를 포괄하기에 범위가 더

에 두었던 것은 순수 조정 문제였다. 하지만 우리가 법에서 고려해야 할 상황은 죄수의 딜레마나 순수 조정 문제가 아닌, 적어도 부분 갈등 게임의 상황이다. 윌드론 역시 정치 상황의 본질을 부분 갈등 게임으로 적절히 묘사하고 있다.¹⁴⁾ 즉, 각자 자신이 추구하는 선호와 기대가 있지만 극단적인 의견불일치와 그로 인한 충돌로 인해 해당 공동체가 해체되기보다는 어느 편으로든 조정되어 유지되기를 바라는 상황, 그것이 바로 우리가 현실성 있게 고민해야 할 조정 문제 상황이다.

그러나 조정 관행 모델을 채택한다 하더라도 조정의 대상이나 문제의 종류를 게임 이론적 가정에 한정할 필요는 없다. 오히려 법이론적 맥락에서라면 게임 이론의 틀을 넘어 조정 문제의 개념을 더 유연하고 폭넓게 이해할 필요가 있다. 예컨대 하딘(Russell Hardin)은 ‘흠에게 있어서의 조정 문제들’을 목록화하는데 그 안에는 심지어 순결, 용맹, 왕위 계승, 약속 지키기 등도 포함되어 있다.¹⁵⁾ 또한 ‘도덕적 조정 문제’¹⁶⁾ 역시 게임 이론에서는 주된 관심 주제

넓다고 볼 수도 있다.

14) Jeremy Waldron, *Law and Disagreement* (Oxford University Press, 1999).

15) Russell Hardin, *David Hume: Moral & Political Theorist* (Oxford University Press, 2007). 85면, Table 4. I.

“흠에게 있어서의 조정 문제들(Coordination Problems in Hume)”:

· 사회질서(social order); · 재산권 규칙들[관행에 대한 흠 고유의 분석을 명백하게 이끄는 고려사항]; · 정의의 규칙들(Rules of justice); · 정부에의 묵인(Acquiescence to government) [dual convention]; · 약속 지키기(Promising- keeping); · 왕위 계승(Royal succession); · 상속 규칙(Inheritance rules); · 국내법(municipal laws) [which vary from place to place]; · 살해 규칙(Rules for murder); · 근친상간 규칙(Incest rules); · 매너(Manners) [‘a kind of lesser morality’]; · 순결(Chastity); · 용맹(Gallantry); · 마차를 위한 교통 규칙(Traffic rules for wagons); · 보행자를 위한 교통 규칙(Traffic rules for pedestrians); · 노 젓는 두 사람(Two men rowing a boat) [not strictly a problem]; · 번덕스러울 수 있는 게임 규칙(Rules of games, which may be capricious); · 스포츠 경기 규칙(Rules for sports contests); · 언어(Language) [The origin of language when there was no language for agreeing on meaning is the issue that drives Lewis’s analysis of convention]; · 화폐로서의 금과 은(Gold and silver as money); · 국제 관계(International relations); · 전쟁 규칙(Rules of war)

“흠에 의해 명확하게 논의되지는 않은 조정 문제들”:

· 운전 관행(Driving convention); · 교통 신호(Traffic signals); · 표준 시각(Standard time); · (컴퓨터) 쿼티 키보드(QWERTY keyboard); · 규범(Norms); · 욕설(Slang)

가 아니지만 규범 영역에서는 중요하게 다룰 필요가 있는 조정 문제 유형 중 하나이다.

(2) 게임 이론적 모델의 가정과 비현실성

조정 문제에 대한 게임 이론적 이해방식은 여러 장점들에도 불구하고 실제 사회적 삶을 제대로 반영하지 못한다. 그리고 그것을 정치 이론이나 법이론 영역에 곧바로 적용하기에는 근본적인 한계가 있다. 울만-마가릿 역시 시인 하듯이, “게임 이론은 사회 규범들에 대한 설명을 위한 유용한 도구를 제공할 뿐 아니라 통찰의 풍부한 원천을 제공한다.” 그러나 “이러한 작업은 게임 이론의 매우 협소한 틀 내부에서는 적절히 수행될 수 없다.”¹⁷⁾ 따라서 적절한 개선이 필요하다.¹⁸⁾

게임 이론적 조정 문제 모델은 두 가지 전제를 갖는다. 첫째, 선택된 현저한 균형점에 대한 대안들은 그 누구의 선호 순위보다 낮은 서열에 있다. 둘째, 경기자들이 갖게 되는 선호의 순위는 완벽하고 이행적이라고 전제된다. 이에 대해서 피니스(John Finnis)는 게임 이론적 조정 문제의 이런 전제는 실천적 합당성의 실제 삶에서는 입증되지 않는다고 지적한다. 실제 삶은 대단히 복잡하고 비이행적이다. 실제 삶 속에서 사람들은 때로는 현저한 해법에 대한 선택으로 지지되는 일치 보다는 해법이 없는 상태를 더 선호할 수도 있

terminology); • 관습(Custom); • 문화(Culture); • 집단 정체성(Group identification) [e.g., ethnic]; • 권력(Power)

16) 조홍식 교수는 사회 구성원들 사이에 서로 다른 가치관이 상충하는 상황을 도덕의 영역에서 벌어지는 조정 문제, 즉 “도덕적 조정 문제”라고 정의한다. 조홍식, 사법통치의 정당성과 한계(박영사, 2009), 36면; 가토프는 조정 문제를 ‘결정-이론적 조정 문제(decision-theoretical coordination problem)’와 ‘도덕적 조정 문제’로 구별한다. 그의 설명에 따르면 전자는 개인들이 바람직한 결과를 성취할 수 있게 하는 반면, ‘도덕적 조정 문제’는 ‘어떤 정의가 있는지’와 ‘특정한 사회적 맥락에서 무엇이 (우연히) 정의로운지’ 사이를 매개하는 규범적 범주이다. Jon Garthoff, “Legitimacy is not Authority,” *Law and Philosophy* (Springer, 2010), 675-681면.

17) Ullmann-Margalit, 위의 책(주9), 16면.

18) Lagerspetz는 게임 이론이 전제하지 않은 것들을 총 9가지로 목록화하여 상세히 설명하고 있다. Eerik Lagerspetz, *The Opposite Mirrors* (Kluwer Academic Publishers, 1995), 30-33면.

다.¹⁹⁾ 균형점에서의 이탈도 게임 이론에서 말하는 것만큼 비합리적이고 이해 불가능할 정도로 나쁜 것이지 않을 수 있다.²⁰⁾ 그리고 어떤 상황이 ‘문제’이고 아닌지, 무엇이 ‘연관된 여건들’과 ‘경기자들’의 한계인지에 관한 폭넓은 의견 불일치가 종종 있다.

또한 현실의 삶에서 대안 선택지들은 다음과 같은 특징이 있다. 첫째, 이는 완전히 제약된 상황이나 이행적 서열순위 안에서 선택을 위한 것으로 나타나지 않는다. 둘째, 이런 상이한 유형의 선(善)은 누군가가 평가를 위해 채택하는 특정한 척도(particular scale)와 별개로는 통약 가능하지 않다. 셋째, 누군가의 평가 잣대에 대한 가장 근본적인 선택들의 근거는 평가될 선의 양(quantities)에 대한 식별이나 평가 가능한 선(assessable good)의 면에서만 결과들 간의 이행적 서수관계 확인일 리 없다는 것이다. 결론적으로 이러한 이유로 인해 게임 이론적 조정 문제 모델은 현실에서 광범위하게 벗어난다고 피니스는 비판한다.²¹⁾ 요컨대 게임 이론 안에서 이해된 조정 문제 모델은 실제 삶의 복잡한 사태들을 너무 쉽게 다룬다는 단점이 있다. 이러한 점은 조정해법 모델을 법이론 영역에 차용하는 데 있어서도 문제점과 한계를 야기할 수 있다.

(3) 법 이론에서의 부적합성과 불충분성

앞서는 게임 이론에 기초한 루이스적 조정 문제 모델이 일반적인 사회적 삶의 영역을 다룸에 있어서 드러내는 포괄적인 한계를 지적했다. 이하에서는 특히 법과 관련된 영역에서 나타나는 문제점을 구체적으로 살펴보고자 한다.

피니스는 ‘법 이론에서 고려되는 조정 문제’와 ‘게임 이론적 조정 문제’는 두 가지 점에서 근본적인 차이가 있다고 지적한다. 하나는 ‘상황 그 자체’에 대한 것이고, 다른 하나는 ‘그런 상황 안에서 당사자들의 이해관심’에 대한 것이다. 그의 설명에 따르면, 첫째, 법 이론에서의 조정 문제는 이해관심의 수렴이나 공유가 부재한 상황까지 포함할 수 있도록 확장되어야 한다. 둘째, 정

19) John Finnis, “Law as Coordination,” *Philosophy of Law* (Oxford, 2013), 67면.

20) Leslie Green, “Law, Co-ordination and the Common Good,” *Oxford Journal of Legal Studies* (1983), 317면, 319면.

21) Finnis, 위의 글(주19), 68면.

치 이론이나 법 이론은 게임 이론에서 체계적으로 배제된 이해관심의 유형까지도 고려해야 한다. 예컨대, 경기 운영과 결과의 공정성에 대한 관심이 대표적이라고 할 수 있다.²²⁾ 통상적인 게임 이론적 조정 문제는 경기자의 승리나 목표의 성취, 혹은 각자의 보수 증진이라는 타산적인 이해관심만을 다룬다. 하지만 법 이론에서 고려되는 조정 문제에서는 정의, 형평, 공정성 등과 같은 보다 근본적인 규범적 가치들이나 공동체적 이상도 중요한 역할을 하기 때문이다.

2. 피니스의 확장된 조정 문제 모델

이러한 문제를 해결하기 위한 가장 적극적인 대안으로서 우선 피니스의 시도를 검토해 볼 필요가 있다. 피니스는 게임 이론적 조정 문제관의 협애성을 극복하기 위해서는 게임 이론이 상정하고 있는 조정 문제 개념의 외연을 확장해야 한다고 보았다. 이에 대한 대안으로 그는 “보다 풍부한 조정 문제관(Richer Conception of Coordination Problem)”을 제안한다. 피니스는 정치 이론이나 법 이론에서 ‘조정 문제’ 용어는 다음의 상황으로 확장된다고 주장한다.

만약 행위 조정이 있다면, 그렇지 않을 경우에는 획득되기 어려운 상당히 유익한 보상이 상당수의 사람들에게 의해 달성될 수 있는데, 이는 *실사 그 상황에서 그 선택에 의해 해를 입거나 최소한 이득을 얻지 않는 다른 사람들도 [그것을] ‘좋은 것’으로 여길 수 있다는 면에서 가능하다.*²³⁾

이렇게 이해된 조정 문제는 ‘연합 행위의 문제’로 확장된다. 결론적으로 피니스가 제안한 “보다 풍부한 조정 문제”는 ‘공동선(common good)을 위한 공동행위’로 재규정된다.²⁴⁾ 피니스의 대안 모델에서는 그가 목표한 바와 같이 조정 문제 개념의 외연이 더 넓고 깊어진 것은 사실이지만, 그 이론의 적절성과 유용성에 대해서는 몇 가지 의문이 든다.

22) Finnis, 위의 글(주19), 69면.

23) Finnis, 위의 글(주19), 69면. (홀림 표시는 원문을 그대로 옮긴 것임.)

24) Finnis, 위의 글(주19), 69면.

첫째, 피니스가 사용하는 ‘조정’, ‘현저성’ 등의 용어가 관행 이론의 맥락에서 형성된 본래적 의미를 얼마만큼 보존하는지 의문이다. 그의 설명에서 굳이 ‘조정 문제’라는 특별하게 정의된 용어를 사용할 실익이 있어 보이지 않는다. 둘째, ‘공동선을 위한 공동 행위’라는 개념은 그것이 담고 있는 도덕성의 무게감뿐만 아니라 포괄성에 있어서도 문제될 수 있다. 전술한 인용문에서도 확인할 수 있듯이, 이런 식의 개념 외연의 과도한 확장은 오히려 문제를 ‘너무 적게’ 해결해 준다는 역설이 발생할 수 있다. 셋째, 이 개념관이 독자적인지에 대해서도 의문이 든다. 그가 제시한 풍부한 조정 문제관의 본질은 일종의 ‘공정 게임 논변(fair play argument)’²⁵⁾의 변주라는 해석도 가능하다. 만약 그러하다면, 공정 게임 논변이 갖는 근본적인 한계를 극복하는 데 ‘공동선’이라는 개념의 결합이 실질적으로 얼마나한 해결력을 제공해 줄 것인가? 넷째, 피니스 식으로 광의의 조정 관념을 채택하게 되면, 과연 그것으로 설명되지 않는, 다시 말해 그 체에 걸리지 않는 사태가 있는지 의문스럽다. 즉 문제를 ‘너무 많이’ 해결함으로써 정작 그 개념을 통해서만 구할 수 있는 가치를 반감시킨다. 이는 결국 구체적 사안에 있어서 실제로는 ‘너무 적게’ 해결해 주는 역설이 발생할 수 있는 것이다.

생각건대, 피니스 식의 방책은 그 취지나 목표에도 불구하고 치러야 할 비용이 적지 않은 것 같다. 또한 그 논의가 기여할 수 있는 실익도 기대만큼 크지 않을 수 있다. 따라서 조정 문제 개념에 대한 이러한 과도한 외연 확장 보다는 문제의 영역과 차원, 그리고 층위를 유형화함으로써 이론을 정교화하는 방식²⁶⁾이 더 안전하고 유익할 것 같다.

25) A. John Simmons, “The Principle of Fair Play,” *The Duty to Obey the Law* (Rowman & Littlefield Publishers, 1999).

26) 예컨대 포스테마가 했던 작업이 여기에 속할 수 있다. 포스테마는 법에 있어서의 다층적인 조정 문제를 층위별로 유형화한다. 자세한 사항은, Gerald J. Postema, “Coordination and Convention at the Foundations of Law,” *The Journal of Legal Studies* (1982), 182-187면 참고.

3. 협력적 상호작용으로서 조정 문제

조정 문제 개념을 분석하기 위한 첫 발판으로서 ‘게임 이론적 조정 문제 모델’을 출발점으로 삼아 그 의의와 한계를 살펴보았다. 그리고 그에 대한 전면적인 대안으로 제시된 피니스의 “보다 풍부한 조정 문제관”도 검토하였다. 그러나 ‘게임 이론적 조정 문제관’과 ‘피니스의 보다 풍부한 조정 문제관’은 각기 나름의 통찰과 장점에도 불구하고 둘 다 극단적인 면이 적지 않다. 특히 ‘법 이론으로서 관행 이론’을 논하는 맥락에서 보면, 전자는 이론적으로 빈곤한 측면이 있고 후자는 필요 이상의 과도한 개념 확장으로 인해 관행 이론이 갖는 특수성이 제거된 듯 보인다. 결론적으로 두 입장이 갖는 문제의식과 통찰을 보존하면서도 양 극단의 중도 어딘가에서 우리는 그 답을 구해야 할 것 같다. 그 실마리를 필자는 포스테마(Gerald J. Postema)의 설명에서부터 찾고자 한다.

(1) ‘전략적 상호작용’과 ‘조정 문제’

포스테마는 조정 문제를 ‘전략적 상호작용(Strategic Interaction: 이하 SI로 약칭함.)’ 문제의 특별한 케이스로 설명한다. ‘사회적 상호작용’이란 총체적으로 그들의 환경에 반응하는 사람들의 문제를 말한다. 그중 특히 ‘전략적 상호작용’ 문제는 다음과 같은 구조적 특성을 갖는다.

① **전략적 상호작용(SI):** 행위자들의 외적 행위는 모든 행위들에 의해 결합적으로 결정된다. 어떤 주체의 행위는 다른 모든 이들의 행위에 의존한다.²⁷⁾

여기서 말하는 ‘전략적(strategic)’이란 “서로의 반응을 민감하게 고려하여 상호 응답적으로 대처한다.”는 특별한 의미로 사용된 것이다. 쉽게 말해 전략적 상호작용의 당사자들은 자신이 어떻게 행동할지를 각자의 선호와 독자적인 판단에 따라 다른 이들의 행위와 독립적으로(‘무관련성’) 결정하지 않는다. 그들은 공동의 관계 속에서 다른 사람들이 어떠한 선호와 기대를 갖고 있고,

27) Postema, 위의 글(주26), 173면.

또 어떻게 행동할지를 예측하면서 그에 상응하게 자신의 선호와 행동을 결정한다. 다시 말해 각자의 행위는 상호 의존적인 특징을 갖는다. 이러한 정의를 충족하는 ‘전략적 상호작용’에는 여러 종류가 있다. 그중에서도 ‘조정 문제’는 사회적 상호작용을 이루는 다음의 세 가지 속성들이 더해지면서 전략적 상황의 다른 원인들로부터 차별화된다.

- ② 이해관심의 대강의 일치(Rough coincidence of Interest): 각 당사자는 비협력보다는 협력에 의해 더 많은 혜택을 얻기 쉽다.
- ③ 상호 조건적인 선호들(Mutually Conditional Preferences)
- ④ 애매성(Ambiguity): 각 행위자들이 “성공적인” 조정이라고 여길 행위 조합이 적어도 둘 이상 존재한다.

포스테마의 설명에 따르면, 조정 문제를 이루는 속성 ② ‘이해관심의 대강의 일치’와 ③ ‘상호 조건적인 선호들’이 전략적 상호작용(SI)을 ‘조정’ 문제로 만든다. 그리고 속성 ④ ‘애매성’이 그것을 조정의 ‘문제’로 만든다. 각 조건을 상세히 살펴보자.

[표 1] 조정 문제의 속성들

- 이해관심의 대략의 일치 + 상호 조건적인 선호들: SI ⇒ ‘조정’ 문제
- 애매성: SI ⇒ 조정 ‘문제’

①	전략적 상호작용(SI)	+	②	이해관심의 대강의 일치	‘조정’
			③	상호 조건적인 선호들	
			④	애매성	‘문제’

이렇게 이해된 ‘조정’ 문제는 반드시 협력적인 속성을 갖게 된다. 그 결과 당사자들 간의 이해관심이 충돌하는 죄수의 딜레마 같은 비협력적 게임 상황은 조정 문제에서 제외된다. 즉 ‘협력적 상호작용’이 ‘조정’의 본질을 이룬다. 여기서 ‘협력적 상호작용’이란 각자의 이해관심이 대략적으로 일치·통합되고, 그것에 기초한 공동 목표를 달성하기 위해 상호 조건적으로 기대와 행위

를 수렴해 나가는 과정을 말한다.²⁸⁾ 요컨대 이러한 설명에 따르면, 기존의 게임이론적인 ‘조정 문제’는 협력적 속성을 갖는 특별한 종류의 협력 문제로 재해석된다. 그렇다면 관행 이론의 맥락에서 협력 문제는 어떠한 특수성을 가질까?

(2) ‘임의성’

협력적 상호작용으로서 조정 문제는 그들의 목표를 어떻게 성취할 수 있는지에 관해 불확실성을 가진 한 집단 구성원들 간의 상호 조건적인 선호 및 행동들의 집합으로부터 발생한다. 그리고 관행 이론은 그 구성원들의 선택들을 서로 연관시키면서 동일한 행위 조합에 기대들을 집중시킴으로써 그런 문제들이 해결된다고 주장한다.²⁹⁾

그런데 문제는 조정을 달성하기 위한 당사자들의 행위 조합이 적어도 둘 이상 존재하는 경우다. 만약 해법이 단 하나라면, 그것은 제안된 지침을 단순히 이행하는 데 불과할 것이다. 즉 ‘진정한 조정 문제’는 일단 그것이 성취되면 어떤 행위자도 그 상태에서의 단독적 이탈행위를 바라지 않는다. 또한 그것을 가능하게 하는 행위 조합인 ‘조정 균형점’이 적어도 둘 이상 존재하기 때문에 ‘문제적’이 된다.³⁰⁾ 관행의 이런 특징을 루이스나 마머³¹⁾는 ‘임의성(arbitrariness)’으로, 포스테마는 ‘애매성’으로 규정한다. 용어상의 차이는 있지만, 조정 관행의 본질이 ‘가능한 해법이 둘 이상 존재함’에 있다는 것은 분명

28) 다른 글에서 포스테마는 ‘협력 문제’의 특징을 다음과 같이 설명한다. 첫째, ‘합리적 행위자들의 선호의 상호 의존성’이다. 그들은 비협조보다는 공동의 계획에 맞춘 다른 이들과의 협력으로부터 더 많은 혜택을 얻는다. 둘째, ‘상호 조건적인 선호들’이다. 어떤 전략이나 행위들은 다른 것들에 비해 선호되는데, 이는 다른 이해당사자들 역시 적절히 관련된 행위들을 선택할 때에만 그러하다. 셋째, ‘불확정성’이다. 다른 이해당사자들이 어떻게 행위할 것인지는 불확정적이다. Gerald J. Postema, *Legal Philosophy in the Twentieth Century: The common law world* (Springer, 2011), 488면.

29) Postema, 위의 글(주26), 469면.

30) Postema, 위의 글(주26), 174면.

31) Marmor, 위의 글(주13).

하다.

다만 여기서 ‘문제(problem)’라는 표현을 꼭 부정적인 어떤 것으로 이해할 필요는 없다. 이는 두 가지 의미를 함축한다고 볼 수 있다. 우선 일상적 용례에서 ‘문제적’이라고 인식되는, 즉 말썽을 일으키고 제거해야 마땅한 부정적 사태라는 뜻이 있다. 하지만 ‘문제’라는 용어는 특수한 어떤 ‘상황(situation)’을 지칭하는 가치중립적인 의미로 이해할 수도 있다. 후자와 같은 온건한 이해가 전제될 때, 애매성이나 임의성과 같이 관행이 갖는 불확정성을 유해하지 않은 것으로 다룰 수 있게 된다.

또한 조정 ‘문제’라는 표현은 해결해야 할 문제가 논리적으로 반드시 선행함을 함축하는 듯 보인다. 마머가 ‘조정 관행’과 구별되는 ‘구성적 관행(constitutive conventions)’³²⁾이라는 별개의 유형을 제시한 배경에도 이와 같은 생각이 자리한다. 그러나 이런 이분법에는 다소간의 의문이 든다. 결론적으로 말하면, 비(非)조정 관행 유형까지 포괄할 수 있는 이론이 필요하다. 이를 위해서는 관행 개념을 구성하는 상황 요소로서 ‘조정’에 대한 개선된 이해와 함께, 해결 과제로서 부정적인 ‘문제’라는 프레임을 제거하는 것이 보다 포용적인 관행 이론 마련을 위한 선결과제일 것이다.

III. 해법 요소

1. 조정 규범: 올만-마가릿의 이분법과 그 한계

조정 관행을 이루는 또 하나의 개념소(概念素)는 ‘조정 해법(coordination solution)’이다. 올만-마가릿은 조정 문제에 대한 해법으로서 조정 규범을 ‘관행’과 ‘법령’ 두 가지로 구별한다. 그의 설명에 따르면, ‘관행’이란 과거에 거듭된 조정 문제들에 대해 시간이 경과함에 따라 수용되고 정립된 해법들이 규범의 지위를 획득한 것이다. 반면에 ‘법령’은 새로우면서도, 시작 단계(outset)

32) 마머의 구성적 관행에 대해서는 이현경, 위의 글(주3), ‘IV. 마머의 복합적 관행 모델’ 참고.

에서부터 조정 문제에 대한 해결책이 규범으로 선포된 경우를 말한다. 올만-마가릿은 관행과 법령의 일반적인 특징을 다음과 같이 설명한다.³³⁾

[표 2] 올만-마가릿의 ‘관행’과 ‘법령’ 구분

관행(conventions)	법령들(decrees)
과거에 거둬진 조정 문제에 대해 규범으로 전환된 확립된 해법	새로운 조정 문제들에 대한 해법으로서의 규범
① 비(非)법정 규범들로서, 제정되고, 공식화되고, 공포될 필요가 없음.	① 법정의(Statutory)
② 어떤 인식 가능한 권위(identifiable authority)에 의해 공표되거나 선포되지 않음. 따라서 보통은 비인격적 규범이나 익명의 규범(anonymous norms)으로 불림.	② 적절히 부여된 권위(반드시 국가 수준의 것일 필요는 없음)에 의해 공표되고 선포됨.
③ 비(非)제도화된, 비(非)조직화된, 그리고 비공식적인 제재들(예컨대 처벌이나 보상)에 관계됨.	③ 그것이 관계된 제재들은 조직화되고, 제도화되며, 공식적이고, 심지어 물리적인 것일 수 있음.

올만-마가릿의 이런 설명은 몇 가지 점에 있어 ‘관행’과 ‘법령’에 대한 이분법을 보인다. 첫째, 조정 문제의 특징과 관련하여, 관행이 해결하는 조정 문제는 과거로부터 거둬 발생해온 것으로 ‘장구(長久)한’ 속성을 갖는다. 반면에 법령이 해결하는 문제 상황은 ‘새로운’ 속성이 더 강조된다. 둘째, 규범 형성 주체의 면에서 보면, 관행은 그것을 정립하는 인격적 권위 주체가 확인되지 않지만 법령은 특정한 권위자나 공식적인 권위체에 의해 제정된다. 셋째, 관행은 비공식적이고 묵시적이지만, 법령은 공식적이고 명시적이며 제도적인 속성을 갖는다.

생각건대, 관행과 법령을 완전히 별개의 실체로 바라보는 이러한 이원론³⁴⁾

33) Ullmann-Margalit, 위의 책(주9), 97면.

34) 그린(Leslie Green)도 관행을 조정규범의 일종으로 보지만, 그는 법규범과 관행이 근본적으로 어떻게 다른지를 보이려고 노력했다. Leslie Green, “Positivism and

은 몇 가지 결합을 안고 있다. 위에 제시한 세 가지를 역순으로 검토해 보자.

우선, 관행의 정체성을 결정짓는 것은 ‘임의성’과 ‘준수 의존성’³⁵⁾이다. ‘비 공식성’이나 ‘묵시성’은 관행의 전범(典範)이 보이는 중요한 특징이긴 하지만 관행성(conventionality)을 규정하는 핵심 요소라고 볼 수는 없다. 예컨대 어떤 관행들은 법적으로 지지되기도 한다. 또한 일부 개별법의 영역, 예컨대 상법이나 국제법의 영역에서는 관행이 공식적인 국가법 이상으로 제도적인 권위를 인정받고 있기도 하다.

필자가 더 중요하게 지적하고 싶은 점은 관행이 해결하는 대상으로서 ‘조정 문제’의 특성에 대한 이분법이다. 필자의 질문은 다음과 같다. “관행은 오직 ‘과거로부터 거듭 반복된 전형적인 문제’만을 해결할 뿐이고 새롭게 등장하는 문제 상황에는 아무런 역할도 할 수 없는가? 그렇다면 새로운 상황에 대해 법령이 마련되기 전까지 그 규범적 공백을 메우는 것은 무엇일까?” 실제로 다양한 실천 현장에서 구성원들의 상호작용을 통해 자율 규범이 형성되고, 그것이 조정 문제에 대한 실질적 해법으로 기능하곤 한다.³⁶⁾ 그러한 경험적 사태도 이론적으로 진지하게 다루어질 필요가 있다. 그리고 관행 개념에 대한 유연한 이해를 통해 양자를 통합하는 대안 이론 마련이 충분히 가능하

Conventionalism,” *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* (1999), 49면.

35) ‘준수 의존성(compliance dependence)’이란 우리가 어떤 관행을 따르는 이유는 (그것이 담고 있는 내용이 무엇이건 간에) 대부분의 사람들이 그것을 준수한다는 사실에 있으며, 궁극적으로는 그것이 나의 이익실현에도 부합하기 때문임을 의미한다. 가령 우측주행의 예를 생각해보자. 한국에서 우리가 우측주행을 하는 것은 ‘좌측’주행보다 ‘우측’주행이 더 낫거나 바람직해서가 아니다(물론 특수하고 예외적인 상황을 제외하고). 우리는 자신을 제외한 거의 대부분의 운전자들이 도로에서 우측주행을 한다는 전제 하에 나 역시 우측 주행을 한다. 즉 일반적 준수라는 그 사실이 내가 우측주행을 하게 하는 행위 이유가 된다.

36) 공식적인 법령을 통한 ‘타율 규제’가 아닌 해당 공동체 안에서 구성원들의 자율적인 상호작용과 자치 규범을 통해 규율되는 ‘자율 규제’ 모델이 이에 해당한다. 이 경우에는, ① 규범 정립자와 수범자가 대체로 일치하고, ② 현장의 목소리를 더 잘 반영하여, ③ 당사자들에게 더 높은 규범 수용력을 가질 수 있다는 강점도 있다. 그리고 관행 규범이 법규의 수준에는 미치지 못하지만 어느 정도 공식성과 제도적 형태를 띠기도 한다. 하지만 울만-마가릿의 이분법은 이런 중간적 성격을 갖는 다양한 형태의 관행적인 자율 규범이나 연성 규범들의 특징을 적절히 설명하기 어렵다.

다고 본다.

요컨대 올만-마가릿의 이분법은 관행과 법령 각각이 완숙한 결정체로서 그 단면적 특성을 비교하는 데는 좋은 설명이 될 수도 있지만, 그것이 답아낼 수 없는 현실의 사태들이 적지 않다. 따라서 이런 설명은 양자의 특징을 대립적인 시각에서 극대화한 일종의 이념형적 구분으로 이해되는 것이 적절하다. 궁극적으로는 보다 건설적인 목표 하에 새로운 관행 개념관의 정립이 요청된다. 결론부터 말하자면, 관행에 대한 이러한 경직된 이해방식(‘정적 관행관’)이 아닌, 관행을 유연하고 환경-적응적이며 역동적인 개체로 바라보고 다루는 ‘동적인 관행 이론’이 필요하다. 이런 배경 하에 본고에서는 관행을 이루는 ‘상황 요소’인 ‘조정 해답’과 관련하여, “조정 해답에서 조정 균형으로”, “내쉬 균형에서 상관 균형으로”라는 2단계 전략을 구사함으로써 이 문제에 접근해 보고자 한다. 이를 통해, 조정 해법에 대한 더 적절하고 유연한 개념관을 궁구한다.

2. ‘조정 해답’³⁷⁾에서 ‘조정 균형’으로

조정 문제는 관련 당사자들의 이해관심의 불일치로 인한 모종의 불균형과 갈등상태를 전제로 한다. 하지만 베손(Samantha Besson)의 저서 『갈등의 도덕성(The Morality of Conflict)』³⁸⁾의 제목에서도 상징되듯이, 갈등의 존재를 반드시 유해하거나 제거되어야 하는 부정적인 것으로 생각할 필요는 없다. 협력 행위나 집단 행위에 있어서 소통의 부재나 단절은 분명 부정적인 의미에서 문제적일 수 있지만, 갈등과 불일치의 상황은 그렇게 일면적으로 볼 수만은 없다. 오히려 불일치로 인한 갈등과 불확실성을 어떻게 이해할지, 만약 극복할 필요가 있다면 그 방책을 어떻게 마련하는지에 따라 그 순기능과 역기능

37) 본고에서는 ‘해법 요소’의 번역어로 ‘해법’과 ‘해답’을 의도적으로 구분한다. 필자는 ‘해법’이란 표현에는 ‘해답’에 비해 더 포괄적이고 유연한 의미를 담고자 했다. 이런 취지를 나타내기 위한 한 방편으로 ‘해답’의 경우 결단주의적 색채가 강한 ‘resolution’이란 영역(英譯)도 고려할 수 있다.

38) Samantha Besson, *The Morality of Conflict: Reasonable Disagreement and the Law* (Hart Publishing, 2005).

을 균형 있게 고려할 수 있다. 이는 ‘상황’과 ‘대응책’의 적절한 관계식을 통해 가능하다.

‘대응책’의 면에서 보면, 관행의 해법 요소의 본질을 어떻게 규정하는지가 각 관행 이론의 성격을 결정짓는다. 고전적 게임 이론이나 일부 실정법학자들에게서 확인되는 친숙한 입장은 ‘행위와 태도의 정규성(regularity)’을 조정 해법의 핵심으로 본다. 상술하자면, 오랜 시간 반복적으로 행해져 온 일치된 행위 수렴에 따른 특정 패턴(정착성)이나 규칙은 명확히 인식 가능한 해답을 제공하며, 그것이 조정 관행의 본질이라는 것이다. 이런 견해는 ‘사실적 안정성’과 ‘예측 가능성’ 확보를 관행의 이념(idea)이나 보호 가치로 생각한다.

조정 해법에 대한 이런 형식주의적이고 경직된 이해방식은 마치 객관식 수학 문제에서의 ‘정답’을 연상시키며 ‘유일하게’ ‘옳은’³⁹⁾ ‘최적의’ 답이라는 확정적 이미지를 덧씌운다. 이러한 ‘정적 관행관’은 명시적인 합의의 산물로 정립된 법령이나 제정법규범과 관행 사이의 차별성을 허물어뜨릴 수 있다. 우리가 관행을 진지하게 논하는 이유는 관행을 다른 어떤 것의 아류나 변형으로 보는 것이 아니라 그 자체의 고유한 가치를 발굴하고 재조명하기 위한 작업임을 상기할 필요가 있다.

‘갈등’과 ‘해법’에 대한 이런 경직된 관념은 “조정 해법으로서의 관행”이라는 명제의 이해와 관련하여 몇 가지 오해와 문제를 야기한다.

첫째, ‘정적 관행관’의 경직된 해법 관념은 관행의 잠재적인 해결력을 무시한다. 이런 견해는 관행을 미해결이나 불확정적인 사태를 종결시키기 위한 수단으로만 규정하며, 오직 기능주의적이고 결과주의적인 관점에서 사태를 평가한다. 하지만 조정 관행의 본질은 일방적 지시나 명령이 아닌 ‘조정 균형점’에의 수렴에 있다. 마치 출렁이는 물결이 어느 순간 잔잔한 고요에 도달하듯이, 관행은 당사자들이 상호작용을 통해 달성한 ‘수렴된 상태’이자 그것을 ‘가능하게 한 방식’까지 포함한다. 또한 적절한 균형점에 도달하기까지의 상호작용 과

39) 여기서 말한 ‘옳음’이 ‘도덕적 참’을 말하는 것은 아니다. 관행주의는 기본적으로 초월주의나 절대주의를 부정한다. 그리고 관행성의 핵심인 ‘임의성’이나 ‘준수 의존성’ 역시 선형적인 도덕성을 전제하지 않는다.

정 역시 결과 못지않게 중요한 의미를 갖는다. 이는 기존의 반복된 문제뿐 아니라 새로운 혹은 잠재적인 문제 상황에도 대처할 수 있는 무형의 자산을 제공할 수 있다. 결론적으로 말해, 비유컨대, 관행을 잠긴 문을 한차례 돌려 여는 딱 들어맞는 ‘그 열쇠 돌리기’로 이해하는 협애화된 시각은 적어도 관행의 본질에 비추어 본다면 부정확할 뿐 아니라 실용적 차원에서도 빈곤함을 보인다.⁴⁰⁾ 보다 유연하고 동적인 개념관과 이론이 필요하다.

둘째, “관행은 자유로이 부유하며 상호 조건적인 선호·기대들을 단일한 균형 상태로 안착시키지만, 그 해법이 모든 이의 관점에서 ‘최적성(optimality)’을 보장하지는 않는다.” 즉, 조정 문제에 대한 해법으로서 ‘준-최적성’의 가능성은 상존하는데, 그로 인해 관행의 존재 자체를 부정해서는 안 될 것이다. ‘관행적 해법’⁴¹⁾의 특별함은 ‘최적점’이 아닌 ‘균형점’에 있으며, 그 본질은 내부 참여자들의 진정한 상호작용을 통한 신뢰 공유 및 공동의 승인에 있다고 필자는 생각한다.

셋째, 관행은 “행위를 위한 지침들(prescriptions for action)을 제공할 뿐 아니라 그 행위들 안에 복잡한 방식으로 구현되고 그로부터 발생하는 행위의 양식들(modes of conduct)이기도 하다.”⁴²⁾ “조정 규범으로서 관행은 사회적 상호작용 문제에 대한 즉각적인 해결책이라기보다는 조화되는 방식으로 보일 수도 있다.”⁴³⁾ 즉 해결에 이르는 과정과 경로의 다원성에도 주목할 필요가 있다.

생각건대, 조정 해법을 확정적 정답으로 바라보는 경직된 이해방식, 즉 ‘정

40) 이런 문제의식은 포스테마의 글에서도 발견된다. 그는 루이스 관행모델의 초기 버전의 문제점을 지적하면서, “협력문제에 대한 균형-해법으로서의 관행”이라는 루이스의 주장에 대해 두 가지 문제를 제기한다. 첫째, 균형은 잠재적 해법인데 루이스는 관행을 실제 해결책으로 주장한다. 둘째, 균형점들은 연관된 체제 하에서 (under some correlated scheme) 이질적인 선택들의 합동(coalescence)과 같은 것을 표상하지 못할 수도 있다. Postema, 위의 책(주28), 490면.

41) 포스테마는 홈·루이스 모델의 ‘관행적 해법’에 대해 ‘강한 버전’과 ‘약한 버전’을 나누어 설명한다. Postema, 위의 책(주28), 490면.

42) Gerald J. Postema, “Custom, Normative Practice, and the Law,” *Duke Law Journal* (Vol. 62, 2012), 728면. 이 글에서 포스테마는 ‘관습(custom)’을 문장의 주어로 삼고 있다. 하지만 포스테마의 여러 저술들을 검토한 결과(적어도 이 문맥에서는) ‘관행(convention)’으로 호환가능하다.

43) Postema, 위의 책(주28), 490면.

적 관행관'은 관행이 갖고 있는 본질적 특성 중 일부를 배제하며, 이는 결국 관행의 존재 자체에 대한 부인으로 이어질 수 있다. 그러나 '열쇠 돌리기 은유'를 통해서도 강조했듯이, 관행은 명확한 해답이나 결단적 지침으로서 기성품이나 발견의 대상이 아니다. 오히려 실제의 관행은 복잡하고 역동적인 면모를 가지며, 생동하고 작동하는 규범(norm in action)의 특징을 보인다. 만약 이 점을 간과한다면, 관행 개념이나 존재 자체를 부정하는 소극적 차원을 넘어, 관행을 통해 획득 가능한 수많은 사회적 자원까지 놓치는 우를 범할 수도 있다.

3. '내쉬 균형'에서 '상관 균형'으로

(1) 내쉬 균형(Nash Equilibrium)⁴⁴⁾

게임 이론에서의 근본적 해법 개념은 후생경제학에서 말하는 '최적점'이 아닌 '균형점'이다. 루이스는 조정 관행의 본질을 내쉬 균형으로 파악한다. '내쉬 균형'이란 그 어떤 행위자도 그것으로부터의 단독적 이탈을 통해 그의 보수가 더 증진될 수 없는 균형점을 말한다. 즉, 그 균형점을 벗어나서 단독으로 행동하면 결국 자기만 손해라는 것이다. 따라서 내쉬 균형에서는, 타산적인 합리적 주체로서 어느 누구도 그러한 행위조합에서 벗어날 유인을 갖지 않는다. 그 결과 내쉬 균형은 자력으로 시행을 강제하는(self-enforcement) 특징을 가지며,⁴⁵⁾ 따라서 '안정성(stability)'과 '자기-영속성'을 확보할 수 있다. 요컨대, 내쉬 균형으로 이해된 관행에의 합리적 행위자들은 어느 누구도 그것에 따르지 않을 합리적 이유가 없으며, 따라서 그 관행은 안정적이고 영속적으로 존재하게 된다.

그런데 앞서 살펴본 문제점들로 인해, 관행에 대한 적절한 분석을 위해서는

44) '내쉬 균형'이란 수학자 존 내쉬(John F. Nash)가 발견한 것으로서, 게임 이론에서의 정의는 다음과 같다. "정규형 게임에서 각 플레이어가 목록에 있는 다른 전략들에 대한 최선반응인 1개의 전략을 갖는다면 그러한 전략의 목록이 내쉬 균형이다." Roger A. McCain(이규익 옮김), *게임 이론*(시그마프레스, 2013), 53면.

45) Gerald J. Postema, "Conventions at the Foundation of Law", *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*(1998), 468면.

대안적 해법 개념이 필요하다는 인식이 있어왔다. 그 결과 내쉬 균형을 일반화하거나 개선하는 여러 해법 개념들이 제안되고 있다. 예컨대 서텐은 관행을 ‘진화적으로 안정된 전략들의 체계’로 분석한다.⁴⁶⁾ 이런 접근에 따르면, 관행은 자기-강제적일 뿐 아니라 안정성도 갖게 된다. 즉 일단 정립되면 그들은 새로운 관행을 수립하려고 시도하는 이탈자들에 의한 침입에 저항할 수 있게 된다. 지금까지 언급한 내쉬 균형이 갖는 특성들은 다음과 같이 요약할 수 있다.

① 각 경기자의 선택은 다른 이들의 선택에 의존한다(‘**의존성**’). 그러므로 설사 그것이 차선(suboptimal)일지라도 만약 경기자 중 한 명의 단독적 이탈이 더 나은 조합을 성취할 수 없다면 그것은 내쉬 균형이 될 수 없다.

② 따라서 내쉬 균형은 안정적이다(‘**안정성**’). 내쉬 균형 안에서 경기자는 다른 이들의 선택을 전제하는 한 어느 누구도 단독적으로 다른 선택을 할 적극적인 이유를 갖지 않으며, 만약 그렇게 행할 시에는 사실상 더 열악한 보수를 얻게 된다. 따라서 내쉬 균형은 자기-강제적이다(‘**자기강제성**’).

③ 즉 다른 사람들의 선호와 선택이 전제되는 한, 각 당사자는 그 선택의 조합, 즉 내쉬 균형점에서 자기 몫을 다하는 것이 합리적이다.⁴⁷⁾ 그 결과 내쉬 균형은 영속적으로 유지될 수 있다(‘**영속성**’).

(2) 상관 균형

또 다른 대안적인 해법 개념으로 오만(Robert Aumann)⁴⁸⁾에 의해 도입된 ‘상관 균형(Correlated equilibrium)’이 있다. 이는 수정된 버전의 레스토랑 게임(혹은 ‘연인 간 갈등 게임’)을 통해 잘 설명된다.

46) Robert Sugden, “Conventions,” *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law* (1998).

47) Postema, 위의 글(주19), 468면.

48) Robert J. Aumann, “Correlated Equilibrium as an Expression of Bayesian Rationality,” *Econometrica* (Vol.55, No.1, 1987).

[표 3] 연인 간 갈등 게임⁴⁹⁾

	레스토랑 A	레스토랑 B
레스토랑 A	2, 1	0, 0
레스토랑 B	0, 0	1, 2

이 게임에서는 두 개의 ‘순수한’ 내쉬 균형—(갑)과 (을) 모두 레스토랑 A에 가거나 레스토랑 B에 가는 전략의 조합—이 있지만, 둘 중 어느 것도 공정(fair)하지 못하다. 왜냐하면 한 경기자가 다른 이에 비해 더 높은 보수를 얻게 되기 때문이다. 가령 (갑)은 레스토랑 A를 선호하지만 만남을 성사시키기 위해 레스토랑 B에 가게 되는 경우—위 칼럼 〈4행 4열〉에 해당—를 생각해 보자. 이런 행위 조합은 만남이 아예 성사되지 못하는 〈1행 2열〉이나 〈2행 1열〉에 비해서는 둘 다 더 높은 보수를 얻는다는 점에서 ‘내쉬 균형’이다. 그러나 그 경우 (갑)은 1의 보수를, (을)은 2의 보수를 얻음으로써 결과적으로 공정하지 못한 특징을 보인다.

이 게임은 ‘혼합 전략’ 내쉬 균형도 가질 수 있다. 말하자면, 각자가 주사위나 동전 던지기와 같은 어떤 ‘무작위 장치(randomizing device)’의 결과에 기초해서 전략을 선택하는 것이다.⁵⁰⁾ 이 경우 상대방도 그 균형점을 따른다고 가정하면, 둘 중 어느 누구도 이 혼합전략 균형으로부터 벗어나서는 더 나은 보상을 얻을 수 없다. 그리고 그 균형점은 두 경기자 모두에게 동일한 기대

49) 〈연인 간 갈등 게임〉은 각자는 다른 레스토랑을 선호하지만, 둘 다 만남이 성사되지 못하는 것보다는 만남을 더 선호하는 상황을 말한다. 연인 (갑)과 (을)은 함께 만나서 식사하기를 원한다. 개인적으로 (갑)은 레스토랑 A를, (을)은 레스토랑 B를 더 선호한다. 하지만 둘 다 서로 만나지 못하는 상황보다는 어디서든 만나서 함께 식사하는 상황을 더 선호한다. 보수표에서 선택 조합의 앞 숫자는 (갑)의 보수를, 뒤는 (을)의 보수를 의미한다.

50) 예를 들어, 연인 (갑)과 (을)이 레스토랑 A,B를 두고 고민하는 경우에, (갑)이 A에 갈 확률이 2/3이고 (을)이 B에 갈 확률이 1/3이라고 해 보자. 이 경우 이 균형점으로부터 얻게 되는 (갑)의 기대 보수는 다음과 같다.

(갑)의 기대보수 = $\text{Prob}(A, A) \times 2 + \text{Prob}(A, B) \times 0 + \text{Prob}(B, A) \times 0 + \text{Prob}(B, B) \times 1 = 2/9 \times 2 + 2/9 \times 0 + 2/9 \times 0 + 2/9 \times 1 = 2/3$. 동일한 방식으로 계산해보면, (을)의 기대 보수도 2/3가 된다.

보수를 제공한다는 점에서 ‘공정’하다. 그러나 순수 내쉬 균형에 비해서는 기대 보수가 더 낮을 수 있다.

그런데 만약 두 경기자가 ‘공동의 무작위 장치(common randomizing device)’에 따라 그들의 행위를 연동시킬 수 있다면, 그들은 새로운 균형점을 얻을 수 있고, 그 균형점은 ‘공정’한 것이 된다. 그리고 파레토는 오래된 혼합전략 균형을 지배하게 된다. 이러한 혼합 전략 조합 역시 게임 이론에서의 균형점에 해당한다. 왜냐하면 어느 누구도 그것으로부터 단독으로 벗어날 이유를 갖지 않기 때문이다. 그러나 혼합 내쉬 균형 경기자들의 행위는 확률적으로 독립적이기 때문에 오리지널 게임에서의 내쉬 균형으로 볼 수는 없다. 이러한 전략 조합에서는 경기자들의 행위가 확률적으로 상관되어 있기에 오만은 이러한 전략 조합을 ‘상관 균형(correlated equilibrium)’이라고 부른다. 상관 균형에 의하면, 경기자들 사이에 사전에 어떤 명시적인 커뮤니케이션에 의존하지 않으면서도 공정하고 상호 만족스러운 결과물을 얻을 수 있게 된다는 장점이 있다.

(3) 상관 균형으로서의 관행

오만의 연구 성과를 기초로, 스컴스(Brian Skyrms)⁵¹⁾와 반더슈라프(Peter Vanderschraaf)⁵²⁾는 관행을 상관 균형의 일종으로 다루어야 한다고 주장한다. 예컨대, 교차로에서의 운전자는 그들의 행위를 신호등 색에 상관시킨다. 즉 ‘신호등 색’이라는 외부의 무작위 장치의 결과에 기초하여 각자의 기대보수가 확률적으로 정해지며 이는 모든 관련 당사자들에게 공정하다. 또한 앞의 레스토랑의 예나 신호등의 예에서 알 수 있듯이, 상관 균형은 종종 조정 문제에 대한 보다 더 만족스러운 해법을 제공한다.⁵³⁾

오만의 상관 균형 개념은 내쉬 균형 개념을 일반화시킨 것이다. 따라서 상

51) Brian Skyrms, "Salience and Symmetry-Breaking in the Evolution of Convention," *Law and Philosophy* (Vol.17, No.4, 1998).

52) Peter Vanderschraaf, "Convention as Correlated Equilibrium," *Erkenntnis* (1995); Peter Vanderschraaf, "Knowledge, Equilibrium and Convention," *Erkenntnis* (1998).

53) Michael Rescorla, "Convention," *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2011), 15-17면.

관 균형 역시 내쉬 균형의 기본적인 특성, 즉 자기-강제적이고 안정적이라는 속성은 그대로 갖고 있다. 다만, 상관 균형에서는 그런 특징들이 절대적이지 않다는 데 특이점이 있다.⁵⁴⁾ 즉 그 균형이 영속적이고 안정적으로 유지된다는 보장이 없다. 왜냐하면 관행 외부의 어떤 장치가 균형 전략의 형성에 필수적인 역할을 하기 때문이다.

상관 균형에서 각 경기자는 공식적으로 게임의 일부가 아닌 어떤 사건이나 다른 정보에 그들의 전략을 연동시킨다. 다시 말해 ‘외생적인 상관성(exogenous correlation)’⁵⁵⁾이 개입된다. 관행에 상응하는 외생적으로 상관된 전략 체계로서 상관 균형은 세계의 사태에 관한 공적인 정보(public information)에 의존한다. 반면 개별 행위자들의 사적인 정보는 그 관행으로부터 일탈하기 위한 아무런 이유도 제공하지 않는다.⁵⁶⁾

그렇다면 관행을 상관 균형으로 규정하는 것은 관행 분석에 있어서 무슨 함의를 갖는가? “내쉬 균형으로서의 관행”에 비해 “상관 균형으로서의 관행”이라는 정의는 어떠한 장점이 있는가? 앞서 살펴본 상관 균형의 이러한 특징들은 ① 관행을 사적 원리가 아닌 공적인 틀 안에서 재규정하며,⁵⁷⁾ ② 공정하

54) “관행은 상관균형으로 인식될 수 있다(Vanderschraaf, 1995). 따라서 관행은 자기 집행적이고 안정적이다. [관행이 절대적으로 자기집행적이라고 말하는 것은 아마도 지나치다. 왜냐하면 누군가의 협력할 이유를 압도할 다른 고려사항들이 있을 수 있기에 어떤 경우에는 그 관행을 위반할 압도적인 이유를 가질 수 있다.] 관행은 또한 공적이고 명명백백하다(transparent). 관행은 집단의 규칙들이며, 단순히 집단 안에서의 사적인 규칙들이 아니며, 공식적으로 알려져 있다.” Postema, 위의 글(주 19), 469면.

55) Vanderschraaf, 위의 글(주52), 74면.

56) Vanderschraaf, 위의 글(주52), 77-78면.

57) 이러한 점은 루이스의 철저한 ‘개별주의’를 벗어나게 하고, 길버트(Margaret Gilbert)의 ‘집단주의’와도 다른 방식으로 관행의 공적인 측면을 설명할 수 있는 기초가 될 수 있다. 사회적 관행에 관한 길버트의 이론은 1989년 출간된 그의 저서 Margaret Gilbert, *On Social Facts* (Routledge, 1989)의 제6장 “Social Convention”에서 최초로 집대성되었다. 그녀는 이후 다양한 후속 저술들을 통해 이론을 정교화하여 발전시켰고, 2008년 발표된 논문 Margaret Gilbert, “Social Convention Revisited,” *Topoi* (2008)에서 보다 정련된 설명을 제시한다. 이 논문은 길버트가 2000년대 이후 발표했던 주요 에세이들을 모아 발간한 논문 모음집 *Joint Commitment: How We Make the Social World* (Oxford University Press, 2014)

면서도 상호 합당하게 수용할 수 있는 균형점을 설명할 수 있다는 점에서 시사하는 바가 크다. 그러나 이를 법적 영역에 더 적극적으로 활용하기 위해서는 상관 균형 개념 역시 적절한 개선과 재해석이 필요하다. 또한 외생 변수로서 ‘공동의 무작위 장치(common randomizing device)’를 어떻게 규정할지에 따라 이는 ‘법적 관행’ 개념이나 그것의 규범성을 설명하는 좋은 이론적 자원이 될 수도 있다. 다만 현재의 상관 균형 해법 관념은 여전히 게임 이론의 틀 안에 있다는 점에서 이는 장점이면서도 한계가 될 수 있다. 예컨대 법이론 영역에서 중요한 주제로 논의되는 ‘정당화된 일탈’이나 ‘불복종의 문제’ 등을 적절히 다루기에는 더 많은 이론적 보충이 필요하다. 또한 상관 균형에서의 그 신호(signal)는 공적(public)이지만 결코 구속적(binding)이지는 않다는 점도 주의 깊게 다룰 필요가 있겠다.

결론적으로 “상관 균형으로서의 관행”이라는 정의 역시 적어도 현재의 수준에서라면 ‘법적 관행’에 그대로 적용하기에는 무리가 있다. 물론 관행 분석에 있어서 상관 균형에 기한 설명이 기존의 ‘내쉬 균형 설명법’ 보다는 진일보하고 많은 가능성을 열어 주는 통로가 될 수 있다. 그러나 이 역시 여전히 게임 이론의 틀 안에서 게임 이론적 개념과 용어에 의존하기에 기존의 문제점을 그대로 간직한다. 예컨대 ‘상관 균형 설명법’에서 말하는 ‘공정한(fair)’에 관한 이해도 법이론에서와는 다르다는 것을 알 수 있다. 따라서 만약 법적 관행 분석에 있어 상관 균형 개념을 받아들여려면, 적절히 수정된 ‘개선된 상관 균형관’이 필요하다.

에 그대로 재수록되었다. 길버트의 관행 이론에 관해서는 이현경, 위의 글(주3), III.-1. 참고.

IV. 관행 개념 재구성과 대안 이론의 필요성

1. 관행 분석의 의의 및 한계: 정적(靜的) 이론을 넘어서

지금까지 관행에 대한 표준적인 설명으로 이해되는 조정 해법 모델을 중심으로 관행의 개념적 구조와 요소를 분석했다. 이러한 분석적 접근을 통해 조정 관행의 개념과 본질에 대한 보다 정교한 이해를 얻었다. 그런데 앞선 비판적 검토 과정을 통해서도 확인하였듯이, 기존의 조정 관행 이론들은 공통적으로 몇 가지 특징과 한계들을 보인다. 이는 다음의 두 가지 차원에서 정리해 볼 수 있다.

첫째, 관행에 관한 경직된 관념과 정적 접근을 보인다.⁵⁸⁾ ‘조정 문제’나 ‘조정 해법’ 개념에 대한 경직된 이해방식은 관행의 실재를 적절히 설명하지 못하는 결함이 있다. 특히 법학자가 진지하게 다루는 관행은 순수하게 추상적인 개념적 산물에 국한되지 않는다. 사회적 실재(social reality)로서 존재하는 관행은 ‘복잡성’과 ‘역동성’⁵⁹⁾을 갖고 있는데, 기존의 이론들은 이러한 점들을 충분히 해명하지 못한다. 이는 관행에 대한 ‘일반 이론’의 차원에서도 한계로 지적될 수 있다. 결론적으로, 관행성(conventionality)을 보존하면서도, 변화와

58) 필자는 관행에 관한 이론을 ‘정적 이론’과 ‘동적 이론’으로 구분한다. 양자의 특징을 간단히 표로 정리하면 다음과 같다. 자세한 사항은, 이현경, “관행에 관한 연구: 사회적 관행에서 법적 관행으로”, 서울대학교 대학원 법학박사학위논문, 2016, 제3장 제2절 참고.

59) 필자가 말하는 관행의 역동적이고 복잡한 실재는 다음의 세 가지 세부 주제로 구체화된다. ‘동적 균형관’, ‘자율적 메커니즘을 통한 진화적 발전’, ‘관행의 존재와 의견불일치의 허용 가능성’ 등이 그것이다. 필자는 동적 관행관을 통해 결론적으로 다음 세 가지 점을 주장한다. 첫째, 관행은 확정적인 폐쇄적 완결체로서 발견의 대상이 아니다. 관행은 실천적 추론의 과정 안에서 형성·유지·발전되는 진화적 산물이다. 둘째, 설사 관행의 형성에 의도적 계기나 유권적 개입이 있다 하더라도, 그 사실이 관행 자격성을 위협하지 않는다. 셋째, 관행의 해석적 측면과 그것을 둘러싼 의견불일치(‘불확정성’)가 있다는 사실이 관행의 존재를 부정하는 근거가 될 수는 없다. 이에 관한 보다 자세한 사항은, 이현경, 위의 글(주58), 제3장 제2절. 참고.

혁신의 가능성을 허용하는 유연한 관행 개념과 동적 이론이 필요하다.

둘째, 정적 관행관은 일반 이론의 차원을 넘어, 법적 맥락에서 유의미하게 다루어지는 ‘법적 관행’ 이론으로서도 한계를 갖는다. 구체적으로 두 가지 점을 말할 수 있다. 우선, ‘법적 관행’의 개념이 필요하다. 오늘날 관행은 본격적인 법적 분쟁에서 판단 대상이 될 만큼 법적으로도 특별한 의의를 갖게 되었고, 그러한 특수성을 반영한 적절한 ‘법적 관행’ 개념이 요청된다. 또한 기존의 조정 해법 모델은 관행의 ‘규범성’ 문제를 충분히 설명하지 못한다. 특히 법학에서는 규범성의 문제가 다양한 차원에서 중요한 주제를 구성하기 때문에, 그러한 문제들을 적절히 설명하고 근거지을 수 있는 ‘법학적 관행 이론’이 필요하다.

요컨대, 이러한 두 차원에서의 한계를 극복하기 위해서는 ‘관행 개념의 재구성’을 포함하는, 궁극적으로는 ‘대안 이론’ 마련으로 나아가야 할 것이다. 그리고 대안 이론은 특히 두 가지 방향, 즉 관행의 ‘동적 측면’과 ‘규범적 측면’을 적절히 설명할 수 있어야 한다.

2. 대안 이론을 향하여: 몇 가지 구성적 요소들

그렇다면 관행 개념 재구성을 포함하는 대안 이론이 갖춰야 할 핵심적인 ‘구성적 요소들(constitutive elements)’은 무엇일까? 개념에 대한 합리적 재구성은 완전히 객관적이고 중립적인 작업일 수 없다. 결국 논자의 인식관심이나 관점을 반영할 수밖에 없다. 그런 점에서 보면, 본고에서 필자는 일관되게 관행의 ‘동적 측면’과 ‘규범적 측면’에 대한 이론화 작업의 필요성을 주장해왔다. 그리고 현실에 존재하는 관행의 복잡성과 역동성에 대한 적절한 해명을 위해서는 ‘생태학적 관점’ 도입이 필수적이다. 지금까지의 논의를 다음과 같이 정리해볼 수 있겠다. 궁극적으로 필자가 주장하는 ‘대안적인 관행 이론’은 다음의 세 가지 ‘구성적 요소들’을 포함한다.

- ① 관행의 역동성(dynamics): ‘관행 동학’
- ② 관행의 복잡성(complexity): ‘관행 생태학’
- ③ 관행의 규범성(normativity): ‘관행 규범학’

이러한 세 가지 요소 중 특히 첫 번째와 두 번째는 별개의 독립된 요소라기 보다는, 상호 중첩적이면서도 상보적인 관계에 있다. 그리고 예시한 관행의 특별한 속성과 그 학문적 접근이 반드시 일대일 대응관계를 이룬다고 볼 수도 없다. 다만, 여기서 강조하고자 하는 점은, 관행의 ‘복잡성’을 포함한 ‘광의의 역동성’을 해명하기 위해서는 ‘생태학적 관점’ 도입이 중요하다는 것이다. 다시 말해 ‘동적 관행 이론’을 구축하기 위해서는 방법론적 차원에서부터 혁신이 필요하며, 이를 관행에 대한 ‘생태학적 접근(ecological approach)’⁶⁰⁾으로 명명할 수 있다.

생태학은 유기체와 환경의 상호작용에 대한 연구 분야로 오늘날 환경과 제도의 맥락에서 개인을 연구하는 기법으로도 발전되어 왔다. 생태학은 상호 영향을 주고받는 인자들 간의 조화와 균형을 중요시한다.⁶¹⁾ 이런 점에서 보면, 관행의 역동적 본성과 복잡성을 포착하고 해명하는데 있어서도 생태학적 관점 도입이 중요한 역할을 할 수 있다. 사회적 관행은 역사와 맥락을 배경으로, 외부 환경 및 구성원들 간의 끊임없는 상호작용을 통한 변화와 적응 과정을 거쳐 발전해가는 산물이라는 인식 전환이 필요하다.

마지막으로 대안 이론은 ‘관행의 규범성’을 구성적 요소로 한다. 그린(Leslie Green)은 “가치 있는 관행은 조정 행위에의 필요에 기초하여 권위에 대한 개별주의적이고 도구주의적인 정당화의 전망을 제공한다.”⁶²⁾고 주장한다. 하지

60) ‘ecological’의 어원은 광의의 생물학 분야인 ‘생태학(ecology)’에서 온 것이다. 그러나 최근 사회학 분야 등에서 활용되고 있는 ‘생태학적 접근’은 그 방법론적 특징만을 차용한 것이다. 필자가 관행 분석에 차용하고자 하는 것도 그 접근 방법에 한정된다. ‘생태학적’이라는 한글 표현이 갖는 선입관과 독특한 어감으로 인해 법이론의 분야에 이 용어를 차용하기에는 어색함이 있다. 그러나 과도한 의역이나 선분은 대체어의 활용은 오히려 불필요한 오해를 초래할 수 있기에 부득이 통상의 번역어 그대로 옮긴다.

61) 법의 영역에서도 이러한 접근을 발견할 수 있다. 머피는 사비니(Savigny), 메인(Maine), 그리고 카터(Carter)에 의해 개척된 법에 대한 생태학적 접근(ecological approach)은 현재는 법인류학과 법사회학에서 다소간 이어져간다고 설명한다. James Bernard Murphy, “Habit and Convention at the foundation of custom”, Perreau-Saussine, Amanda, · Murphy, James Bernard (Ed.), in *The Nature of Customary Law*, Cambridge University Press, 2007, 78면.

62) Leslie Green, *The Authority of the State* (Oxford University Press, 1999), 96면.

만 동시에 그는 관행주의가 법의 규범성 설명에는 실패한다고 단언한다. 대안적인 관행 이론은 이러한 회의론에도 적절히 대응할 수 있어야 한다. 이러한 요청을 구체화해보면, 특히 법이론으로서 관행 이론, 즉 ‘법학적 관행 이론’은 ① 관행이 규범인지 여부(‘개념분석적 차원’), 만약 그러하다면 ② 그 규범성의 원천은 무엇인지(‘정당화 차원’), 그리고 ③ 소위 ‘나쁜 관행’⁶³⁾의 경우에는 그 효력과 준수 의무는 어떻게 되는지(‘평가적 차원’) 등 다양한 차원에서 규범성 문제를 다룰 수 있어야 할 것이다.

3. 기능주의적 조정 이론을 넘어

그런데 조정 관행 모델을 받아들일 경우에는 또 다른 차원의 문제가 남아 있다. 말하자면, 일부 논자들은 관행의 본질을 조정 문제에 대한 해법으로 설명하는 ‘조정 관행 이론’을 ‘조정 이론’으로 치환하고, 양자를 꼭 같은 것으로 취급하기도 한다는 점이다. 하지만 ‘기능주의적 조정 관행 모델’이 관행의 전부는 아니다. ‘관행의 본질 = 조정 해법 = 조정 관행’이라는 일원론적 이해는 부적절한 면이 있다. 즉, 관행이 정의(定義)상 반드시 조정 문제를 해결해야 하는지에 대해 의문을 제기할 수 있다.⁶⁴⁾ 즉, 엄밀한 의미에서의 게임 이론적 조정 문제 해결의 상황을 전제하지 않는, 하지만 관행성의 핵심 요소—임의성과 준수 의존성—를 충족하고 있는 ‘비(非)조정 관행’도 가능하다. 또한 법의 주된 기능 역시 조정 문제 해결에 결코 국한되지 않는다. 우리는 양자를 모두

63) 양선숙 교수도 지적하기를, “통상적 관행론은 나쁜 관행과 좋은 관행을 구분할 수 없다. CR을 만족하여 ‘관행’으로는 분류되지만 규범성을 갖는다고는 할 수 없는 행동규칙이 가능하다. 만약 우리에게 법 이론으로서의 관행론이 있어야 한다면, 그것은 관행 일반에 대한 이론에서 그치는 것이 아니라 ‘좋은 관행’을 적절하게 설명하는 것이어야 할 것이다.” 양선숙, “법, 규범성, 그리고 규칙 준수의 동기에 대한 관행론적 이해,” 법철학연구 제15권 제3권, 2012, 48면.

64) 예컨대 서텐은 ‘소유 관행(conventions of property)’과 ‘호혜성 관행(conventions of reciprocity)’을 반례로 들면서, 양자는 조정 문제를 해결하지는 않지만 관행이라고 반박한다. 마머도 추상화된 개념적 차원에서의 “게임들”보다는 체스게임과 같은 실제의 게임(actual)에 주목함으로써 조정 문제의 해결책은 아니지만 다른 특별한 기능을 수행하는 ‘구성적 관행’이라는 새로운 관행 모델을 제안한다. Rescorla, 위의 글(주53), 17-19면.

포괄할 수 있는 보다 유연하고 적합한 관행 개념의 틀을 마련할 필요가 있다.

또한 이런 입장은 법이론의 관점에서 보면 법의 본성이나 제1의 기능은 조정 문제 해결이라고 주장하는 ‘조정적 법관념’과도 연결된다. 법에 관한 조정 이론적 설명, 특히 법의 권위를 조정 문제에 대한 해법 제공이라는 법의 기능에 기해 설명하려는 학자들은 많다. 법질서의 특성에 대한 조정 모델⁶⁵⁾ 혹은 조정적 법관념을 주장하는 이들은 세부 지점에서 차이가 있긴 하지만 공통되게 법의 본성을 ‘조정’이라는 핵심 기능으로부터 파악하는 입장으로 이해할 수 있다. 그러나 그중 일부는 ‘조정 이론’은 발달되어 있지만 정작 ‘관행’의 본성에 대한 진지한 고민이나 탐구는 부족하다. 그들은 대체로 조정 문제 상황에 집중하고 그에 대한 해결책으로 큰 부담감 없이 관행을 제시하고 논의를 종결하는 듯 보인다. 하지만 이러한 접근은 적절하지 못하다. 만약 조정 이론에만 머물게 된다면, 조정적 법 모델은 특정 이론의 보조 전제나 배경으로서의 설명적 역할 이상으로 나아가기 어려울 것 같다. 결론적으로 대안 이론은 이러한 문제점과 한계도 보완할 수 있어야 할 것이다. 요컨대, ‘조정’ 이론은 궁극적으로 조정 ‘관행’ 이론으로 진보해야 한다. 그리고 대안적인 법학적 관행 이론은 앞서 제시한 세 가지 요소를 필수로 삼아 법적 관행의 본성 해명에 있어서도 중요한 통찰을 제공해 줄 수 있을 것이다.

V. 맺으며

관행이란 합리적 주체가 공동의 조정 혹은 협력 문제에 직면하여 실천적인

65) “(…)법의 효력, 권위, 그리고 자율성을 이해함에 있어 관행의 역할을 탐구한 다른 철학자들로는 Raz(1977); Finnis(1980, 1989); Gans(1981); Marmor(1998, 2009); and Green(1983)이 포함된다. 이 문헌들은 형식적인 게임 이론에 호소하고 있긴 하지만, 전체적으로는 법에 대한 조정 설명과 법복종에의 도덕적 근거를 산출하는 법의 역량(capacity)이라는 점에서 법의 규범성 사이의 관계에 집중되어 있다.” Gillian K. Hadfield, and Barry R. Weingast, “What is law? a coordination model of the characteristics of legal order”(2012), 502면(강조 및 밑줄은 필자에 의한 것임). 이 글은 법철학 및 사회과학 영역에서 법에 관한 조정 이론적 설명을 시도한 여러 분과와 이론가들의 지형을 잘 정리 소개하고 있다. 특히, 502-505면 참고.

추론 과정을 통해 수립된 균형점으로서, 명시적인 합의나 약속이 없이도 행위자들 간의 사회적인 상호작용을 통해 형성되고 자율적으로 존속하는 묵시적인 규범질서이다. 그리고 그 자체 메커니즘상 참여자에게 행위이유를 제시하고 준수의무를 창출하는 사회적 규칙이다. 이러한 기본적인 입장을 전제로, 이 글에서는 ‘조정 관행 모델’을 중심으로 관행의 개념 구조와 요소를 분석했다. 즉, 상황·해법·상호작용 요소의 면에서 관행을 분석하면서 관행의 본질에 대한 보다 정교화된 이해를 구하고자 했다.

관행 개념에 대한 분석적 접근을 통해 필자는 기존의 조정 관행 이론들은 사회적 관행에 관한 ‘일반 이론’의 차원에서, 그리고 ‘범이론’의 차원 양측에서 결함이 있음을 지적하였다. 즉, 전자는 관행의 역동성과 복잡성을 제대로 포착하지 못한다는 점, 그리고 후자는 관행의 규범성을 충분히 해명하지 못한다는 점을 말한다. 이러한 두 차원의 한계를 보완하기 위해, 필자는 궁극적으로 대안 이론 마련이 필요함을 주장했다. 대안 이론은 법적 관행 개념 재구성을 포함하며, 궁극적으로 범이론의 과제에 응답할 수 있는 ‘법학적 관행 이론’을 의미한다. 또한 대안 이론은 관행의 본질을 조정 문제 해결로만 바라보는 기존의 일원론적인 기능주의적인 조정 관행 이론이나 조정적 법관념의 문제점도 보완할 수 있어야 한다. 결국 조정 이론과 관행 이론, 그리고 법 본성론 간의 적절한 관계 설정과 개선 노력이 중요하다.

본고에서 수행한 조정 관행의 개념적 구조와 요소에 대한 분석적 탐구는 이러한 대안적인 법학적 관행 이론을 구축하기 위한 중요한 분석적 기초를 제공하는데 기여할 수 있을 것이다.

참고문헌

1. 국내문헌

1. 단행본

- 박효중, 『국가와 권위』, 박영사, 2001.
- 조홍식, 『사법통치의 정당성과 한계』(제2판), 박영사, 2009.
- 최정규, 『이타적 인간의 출현』, 뿌리와 이파리, 2009.
- 최정규, 『게임이론과 진화 다이내믹스』, 이음, 2009.

2. 논문

- 박준석, “관행과 법의 지배,” 『법철학연구』, 제16권 제3호, 한국법철학회, 2013.
- 안준홍, “87년 체제와 승인규칙의 변화,” 『외법논집』, 제36권 제4호, 2012.
- 안준홍, “승인율의 규범성에 대한 일 고찰,” 『법철학연구』, 제16권 제3호, 한국법철학회, 2013.
- 양선숙, “수도-서울 명제의 ‘관습헌법’ 성립에 대한 비판적 검토,” 『법철학연구』, 제9권 제2호, 한국법철학회, 2006.
- 양선숙, “흙의 정의론 연구—재산권 규칙의 정립과 관련한 묵계(Convention)를 중심으로,” 『부산대학교 법학연구』, 제51권 제4호, 2010.
- 양선숙, “법, 규범성, 그리고 규칙 준수의 동기에 대한 관행론적 이해,” 『법철학연구』, 제15권 제3권, 한국법철학회, 2012.
- 이정훈, “법실증주의 승인율과 관행에 관한 연구,” 『법철학연구』, 제10권 제2호, 한국법철학회, 2007.
- 이정훈, “법개념 논쟁을 통해 본 관행과 법해석의 재량,” 『문학·사학·철학』, 제15호, 한국불교사연구소, 2008.
- 이현경, “관행에 관한 연구: 사회적 관행에서 법적 관행으로,” 서울대학교 대학원 법학박사학위논문, 2016.
- 이현경, “사회적 관행 이론의 세 모델: 비판적 고찰,” 이화여자대학교 법학논집, 제21권 제3호, 2017.

II. 외국문헌

1. 단행본

데이비드 흄(이준호 옮김), 『도덕에 관하여』(수정판), 서광사, 1998.

로저 A. 맥케인(이규익 옮김), 『게임 이론』, 시그마프레스, 2013.

Andrei Marmor, *Social Conventions: From Language to Law*, Princeton University Press, 2009.

David Lewis, *Convention*, Blackwell Publishing, 1969/2002.

David Hume, *Enquiries Concerning the Principles of Morals*, L.A.Selly-Bigge (Ed.), Oxford Clarondon Press, 1951.

Douglas G. Robert H. Baird · Gertner · Randa C.Picker, *Game Theory and the Law*, Harvard University Press, 1998.

Edna Ullmann-Margalit, *The Emergence of Norms*, Oxford University Press, 1977.

Eerik Lagerspetz, *The Opposite Mirrors*, Kluwer Academic Publishers, 1995.

Gerald J. Postema, *Conventions at the Foundation of Law*, The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, 1998.

Gerald J. Postema, *Legal Philosophy in the Twentieth Century: The common law world*, Springer, 2011.

James Bernard Murphy, “Habit and Convention at the foundation of custom,” Perreau-Saussine, Amanda, · Murphy, James Bernard (Ed.), in *The Nature of Customary Law*, Cambridge University Press, 2007.

Jeremy Waldron, *Law and Disagreement*, Oxford University Press, 1999.

Leslie Green, *The Authority of the State*, Oxford University Press, 1999.

Margaret Gilbert, *On Social Facts*, Routledge, 1989.

Margaret Gilbert, *Joint Commitment: How We Make the Social World*, Oxford University Press, 2014.

Russell Hardin, *David Hume: Moral & Political Theorist*, Oxford University Press, 2007.

Samantha Besson, *The Morality of Conflict: Reasonable Disagreement and the*

Law, Hart Publishing, 2005.

2. 논문

A. John Simmons, "The Principle of Fair Play," *The Duty to Obey the Law*, Rowman&Littlefield Publishers, 1999.

Andrei Marmor, "On Convention," *Synthese*, 1996.

Brian Skyrms, "Salience and Symmetry-Breaking in the Evolution of Convention," *Law and Philosophy*, Vol.17, No.4, 1998.

Gerald J. Postema, "Coordination and Convention at the Foundations of Law," *The Journal of Legal Studies*, 1982.

Gerald J. Postema, "Custom, Normative Practice, and the Law," *Duke Law Journal*, Vol.62, 2012.

Gillian K. Hadfield, and Barry R. Weingast, "What is law? a coordination model of the characteristics of legal order," 2012.

John Simmons, "The Principle of Fair Play," *The Duty to Obey the Law*, Rowman & Littlefield Publishers, 1999.

Jon Garthoff, "Legitimacy is not Authority," *Law and Philosophy*, Springer, 2010.

John Finnis, "Law as Coordination," *Philosophy of Law*, Oxford, 2013.

Leslie Green, "Law, Co-ordination and the Common Good," *Oxford Journal of Legal Studies*, 1983.

Leslie Green, "Positivism and Conventionalism," *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 1999.

Margaret Gilbert, "Social Convention Revisited," *Topoi*, 2008.

Michael Rescorla, "Convention," *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2011.

Peter Vanderschraaf, "Convention as Correlated Equilibrium," *Erkenntnis*, 1995.

Peter Vanderschraaf, "Knowledge, Equilibrium and Convention" *Erkenntnis*, 1998.

Robert J. Aumann, "Correlated Equilibrium as an Expression of Bayesian Rationality," *Econometrica*, Vol.55, No.1, 1987.

Robert Sugden, "Conventions," *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, 1998.

Abstract

**Conceptual Structure and Constitutive Elements
of Coordination Convention
—Reconstruction of the Concept of Convention
and the Analytic Foundation for an Alternative Theory—**

Lee, Hyun-Kyung*

Conventions are very significant in legal theory and legal practice, as well as in our ordinary civic life. Nevertheless, jurisprudential research on the concept, nature, validity, and legal implications, of convention has not been done enough.

Previous theories on social conventions can be categorized into three approaches, namely: (i) the ‘coordination solution model’ of Hume and Lewis which sees convention as a solution for coordination, (ii) the ‘alternative model’ which has emerged based on a rejection of Lewis’ fundamental premises, (iii) and the ‘multi-layered alternative model’ of Marmor which accepts the Lewisian coordination convention but proceeds to suggest a new type of understanding which Lewis fails to explain. Among these theories, based on the ‘coordination solution model’ which is considered to be the standard explanation to conventions, this article attempts to analyse the conceptual structure and elements of coordination convention.

The coordination convention consists of (i) coordination as the ‘situation factor’, (ii) the ‘solution factor’ which is the normative response thereto,

* Senior Researcher, Center for the Study of Legal Theory, Seoul National University/
Collegiate Professor, School of Undergraduate Studies, DGIST.

(iii) and the ‘interaction factor’. Among these, this article concentrates on (i) and (ii) to analyse the conceptual structure of convention. And thereupon, the author indicates that the existing models on coordination convention have, in spite of various merits, certain problems and limits on two dimensions: namely, the dimension of a ‘general theory’ on social conventions, and the dimension of a ‘legal theory’ thereon. In the former sense they cannot appropriately grasp the ‘dynamic and complex’ nature of conventions, whereas they fail to elucidate the ‘normativity’ of convention in the latter sense. In order to overcome these defects of the existing theories, the author claims for the eventual necessity to formulate an ‘alternative legal convention theory’. The alternative theory includes a reconstruction of the concept of ‘legal convention’, and has as its constructive elements the elucidation of the (i) dynamism (dynamics of convention), (ii) complexity (ecology of convention), and (iii) normativity (normative science of convention) which social conventions have. The analysis of the conceptual structure and elements of conventions in this article will contribute to the analytic foundation to formulate an alternative legal theory on conventions.

색인어

관행(Convention), 조정 관행(Coordination Convention), 루이스(David Lewis), 게임 이론(Game Theory), 내쉬 균형(Nash Equilibrium), 법적 관행(Legal Convention)